

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 421/2566      พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด      โจทก์  
นาย ก.      จำเลย

ป.อ. มาตรา 2 วรรคหนึ่ง, มาตรา 277 วรรคหนึ่ง (เดิม), มาตรา 277 วรรคหนึ่ง (ใหม่), มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม), มาตรา 279 วรรคสี่ (ใหม่)  
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 6 (2) วรรคหนึ่ง (เดิม), มาตรา 6 (2) วรรคหนึ่ง, มาตรา 52 วรรคสาม

ต. พาผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กไปส่งให้จำเลย และจำเลยรับตัวผู้เสียหายไว้ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อนำตัวผู้เสียหายไปกระทำชำเราซึ่งจำเลยได้กระทำแล้วหลายครั้ง ทั้งยังไปติดตามผู้เสียหายในที่สาธารณะโดยส่งเสียงโวยวายจนบุคคลในสถานที่ดังกล่าวสามารถสังเกตได้ถึงความผิดปกติ การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจเหนือผู้เสียหายที่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจที่ตนไม่อาจปฏิเสธได้เพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้เสียหายในทางเพศโดยการกระทำชำเราผู้เสียหาย แลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่ ต. ได้รับจากจำเลย อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น ทั้งการกระทำของจำเลยยังเป็นการทำให้ผู้เสียหายมีฐานะคล้ายทาสอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบ จึงเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์

อนึ่ง โจทก์บรรยายฟ้องสำหรับความผิดฐานค้ามนุษย์ว่า จำเลยกระทำความผิดเมื่อระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลากลางวัน ต่อเนื่องกัน โดยเป็นการบรรยายฟ้องในลักษณะต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่จำเลยกระทำพฤติการณ์ดังกล่าวจนถึงวันสุดท้ายที่จำเลยกระทำความผิดเมื่อ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.

2551 พ.ศ. 2562 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ก่อนวันสุดท้ายที่จำเลยกระทำ ความผิดโดยให้ยกเลิกความในมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความตามมาตรา 6 ที่บัญญัติใหม่แทน ซึ่งการกระทำของจำเลยตามฟ้องยังคงเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ และคงกำหนดโทษตาม มาตรา 52 อันเป็นระวางโทษเดิม กฎหมายเดิมและที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึง เป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำผิดด้วยกัน และเมื่อกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่เป็น คุณจึงต้องบังคับตามกฎหมายเดิมและที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตาม ป.อ. มาตรา 2 วรรคหนึ่ง สำหรับข้อที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำอนาจารและกระทำชำเราผู้เสียหาย โจทก์บรรยายฟ้องทำนองว่า เมื่อระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 วันเวลาใดไม่ปรากฏ ชัด ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลากลางวัน ต่อเนื่องกัน จำเลยใช้อวัยวะเพศและ นิ้วสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย โดยศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยกระทำความ ผิดก่อน พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ใช้ บังคับ และพิพากษาลงโทษจำเลยฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคหนึ่ง (เดิม) นั้น เห็นว่า พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวล กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 แห่ง ป.อ. และให้ใช้ความใหม่แทน และมาตรา 3 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ เพิ่มนิยามของการกระทำชำเราเป็นมาตรา 1 (18) ของ ป.อ. ว่า "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้ กระทำล้วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และโดยที่มาตรา 277 วรรคสอง (เดิม) บัญญัติให้การ กระทำชำเราหมายความรวมถึงการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศของผู้อื่น ซึ่งการ ใช้นิ้วล้วงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้อื่นจึงถือว่าเป็นการกระทำชำเราด้วย ดังนั้น ก่อนกฎหมายแก้ไข การใช้อวัยวะเพศและนิ้วสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสีย

หายจึงเป็นความผิดฐานกระทำชำเราตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคหนึ่ง (เดิม) เพียง  
บทเดียวเท่านั้น และเมื่อกฎหมายแก้ไขแล้ว การใช้ฉันทาลงเข้าไปในอวัยวะเพศ  
ของผู้อื่นจึงไม่เป็นการกระทำชำเราตามมาตรา 277 อีกต่อไป แต่จะเป็นความผิดฐาน  
กระทำอนาจารโดยการล่วงล้ำอวัยวะเพศตาม ป.อ. มาตรา 279 วรรคสี่ (ที่แก้ไข  
ใหม่) มิใช่ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง  
(เดิม) ตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย นอกเหนือไปจากการทำความผิดฐานกระทำ  
ชำเราตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่) ด้วย แต่เมื่อการใช้อวัยวะเพศและ  
ฉันทาลงเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องเป็นคราว  
เดียวกันด้วยความมุ่งหมายที่จะกระทำชำเราผู้เสียหาย การกระทำอนาจารของจำเลย  
จึงเป็นการกระทำที่รวมอยู่ในการกระทำชำเรา จึงเป็นการกระทำความผิดเป็น  
ความผิดต่อกฎหมายหลายบท และแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน คือมีระวางโทษจำคุก  
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท ซึ่งต้องให้ลงโทษฐาน  
กระทำชำเรา และเมื่อการจะปรับบทลงโทษตามความผิดทั้งสองฐานตาม  
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ต่างก็มีอัตรา  
โทษสูงกว่าความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ตามมาตรา 277  
วรรคหนึ่ง ตามกฎหมายเดิมซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่  
แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทต้องถือว่าไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่ง  
เป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลย ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อ  
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกา  
ย่อมมีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขโดยปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา  
195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ที่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษาแก่ส่วนที่ศาลชั้นต้น  
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตาม  
ป.อ. มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม) ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อการ  
ทำความผิดฐานค้ามนุษย์ของจำเลยเป็นกรรมเดียวกันกับความผิดฐานกระทำ

ข้าเรดังกล่าว จึงต้องลงโทษจำเลยตามความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4, 6, 52 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90, 91, 277, 279

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (1) (2) วรรคหนึ่ง, 52 วรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง (เดิม), 279 วรรคหนึ่ง (เดิม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานค้ามนุษย์ซึ่งได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี จำคุก 8 ปี ฐานกระทำซ้ำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำซ้ำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 7 ปี รวมจำคุก 15 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีคุ้มครองพิพาทฯ แก่เป็นว่า ความผิดฐานคุ้มครองซึ่งได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานคุ้มครองซึ่งได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 8 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เด็กหญิง ข. ผู้เสียหาย สัญชาติพม่า เป็นบุตรนาง ต. และนาย น. พักอาศัยอยู่ที่ชุมชนอิสลาม ขณะเกิดเหตุ ผู้เสียหายอายุ 14 ปี นาง ต. ประกอบอาชีพรับจ้างขายน้ำชาที่ร้านขายน้ำชาและรับจ้างทำความสะอาดบ้านให้แก่จำเลย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นางสาว ด. เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ผ. พาผู้เสียหายไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าผู้เสียหายถูกจำเลยข่มขืนกระทำชำเรา วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลย ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการฟ้องนาง ต. ต่อศาลชั้นต้น นาง ต. ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษในความผิดฐานเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี และเป็นผู้สืบสันดาน ฐานบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติดนไม่สมควรหรือน่าจะ ทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด ฐานคุ้มครองซึ่งได้กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามคดีหมายเลขแดงที่ คม.1/2563 ของศาลชั้นต้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอายุ 14 ปี ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังโดยต้องพิจารณาประกอบพยานอื่นของโจทก์ คำเบิกความของผู้เสียหายไม่มีรายละเอียดและไม่ปรากฏว่าเหตุใดนาย น. บิดาของผู้เสียหายจึงไม่ทราบเรื่อง โจทก์มิได้นำคนขายโรตีสี่ที่ทราบเรื่องจากมารดาของผู้เสียหายมาเบิกความ คำเบิกความของนางสาว ด. เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ผ. เป็นพยานบอกเล่า การตรวจร่างกายของผู้เสียหายไม่พบสารคัดหลั่งของจำเลย พยานหลักฐานของโจทก์มีความสงสัยต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยนั้น ปัญหานี้โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่า เมื่อวันเดือนปีใดจำไม่ได้แต่ประมาณ 2 ปี แล้ว นาง ต. มารดาผู้เสียหายพาผู้เสียหายไปส่งที่รถยนต์ของจำเลย นาง ต. บอกผู้เสียหายว่า จำเลยจะพาไปซื้อขนม หลังจากนั้นจำเลยได้ขับรถยนต์พาผู้เสียหายไปจอดบริเวณที่มีต้นไม้แล้ว จำเลยให้ผู้เสียหายถอดเสื้อผ้าออก แต่ผู้เสียหายไม่ยินยอม จำเลยจึงขับรถยนต์ไปส่งผู้เสียหายที่ข้างทาง จำเลยบอกผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายไม่ทำตามคำสั่งของจำเลย ต่อไปจะไม่ให้เงินใช้และจะไม่จ่ายค่าเช่าบ้านให้นาง ต. อีก ในวันเดียวกันนั้นจำเลยขับรถจักรยานยนต์มาที่บ้านผู้เสียหายและบอกนาง ต. ถึงเรื่องที่ผู้เสียหายไม่ยินยอมให้จำเลยกระทำชำเรา นาง ต. ดุด่าผู้เสียหายและบอกให้ผู้เสียหายทำตามคำสั่งจำเลย โดยบอกว่าหากผู้เสียหายไม่ยินยอมทำตามความต้องการของจำเลย ผู้เสียหายและนาง ต. จะไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีเงินใช้ และไม่มีเงินที่จะคืนให้แก่จำเลย หลังจากนั้นอีก 2 วัน เวลาประมาณ 8 นาฬิกา นาง ต. พาผู้เสียหายไปส่งให้จำเลยซึ่งจอดรถยนต์รออยู่ที่บริเวณสุเหร่า แล้วจำเลยขับรถยนต์พาผู้เสียหายไปจอดบริเวณสถานที่เดิมอีก จำเลยใช้อุปกรณ์สำหรับบังแดดปิดกระจกหน้ารถเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกมองเข้ามาเห็นภายในรถยนต์ แล้วจำเลยถอดเสื้อผ้าของผู้เสียหายและจำเลยออกและปรับเบาะนั่งของผู้เสียหายให้เอนลง จำเลยใช้นิ้วล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายและใช้อวัยวะเพศของจำเลยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย

จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายจนสำเร็จความใคร่แล้วขับรถพาผู้เสียหายไปส่งให้นาง  
ต. ซึ่งรออยู่ที่สุเหร่า จำเลยจะขับรถมารับผู้เสียหายและพาไปกระทำชำเราตามสถานที่ต่าง ๆ  
ในลักษณะเช่นนี้เรื่อยมาสัปดาห์ละ 2 ถึง 3 ครั้ง โดยใช้รถยนต์สีขาวบ้าง  
รถยนต์ซึ่งมีสติ๊กเกอร์รูปดอกกุหลาบสีแดงติดไว้ที่หลังรถบ้าง จำเลยยังพาผู้เสียหาย  
ไปกระทำชำเราที่บ้านของจำเลยในขณะที่ภริยาไม่อยู่ จำไม่ได้ว่ากี่ครั้ง จำเลยเคยให้  
เงินนาง ต. หลายครั้ง ครั้งละ 3,000 ถึง 4,000 บาท และวันที่ 13 กันยายน 2562  
จำเลยขับรถยนต์พาผู้เสียหายไปกระทำชำเราที่บริเวณถนนใกล้กับสำนักงาน ย. ต่อ  
มาวันที่ 14 กันยายน 2562 ผู้เสียหายไปร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิ ผ. สำนักงาน ย.  
จำเลยขับรถจักรยานยนต์ไปตามผู้เสียหายให้กลับบ้าน ส่งเสียงเอะอะโวยวายจน  
นางสาว ต. เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ผ. เห็นผิดสังเกตไม่ยอมให้ผู้เสียหายไปกับจำเลย  
นางสาว ต. สอบถามผู้เสียหายถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ผู้เสียหายเล่าเรื่องที่ถูกระทำชำเรา  
นางสาว ต. พาผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจ  
ภูธรแม่สอด นาง ต. เบิกความว่า พยานเป็นมารดาของผู้เสียหาย พยานให้ผู้เสียหาย  
ไปทำความสะอาดบ้านของจำเลย มิได้ให้ไปให้จำเลยกระทำชำเรา พยานให้การต่อ  
พนักงานสอบสวน นางสาว ต. เบิกความว่า พยานให้การต่อพนักงานสอบสวน เห็นว่า  
นอกจากโจทก์มีผู้เสียหายเบิกความยืนยันว่า จำเลยพาผู้เสียหาย อายุ 14 ปี ไปที่ต่าง  
ๆ โดยจำเลยให้เงินแก่นาง ต. ครั้งละ 3,000 ถึง 4,000 บาท และจำเลยกระทำ  
อนาจารกับกระทำชำเราผู้เสียหาย สอดคล้องกันในสาระสำคัญกับที่ผู้เสียหายให้การ  
ต่อพนักงานสอบสวนแล้ว โจทก์ยังมีนาง ต. และนางสาว ต. เบิกความสนับสนุนว่า  
พยานทั้งสองให้การต่อพนักงานสอบสวน โดยนาง ต. ให้การว่าเป็นผู้บอกให้ผู้เสีย  
หายไปกับจำเลยและยินยอมให้จำเลยกระทำอนาจารและกระทำชำเราเพื่อแลกกับหนี้  
40,000 บาท ค่าเช่าบ้าน และค่าใช้จ่ายที่จำเลยจะให้อีก โดยต่อมาจำเลยออกค่าเช่า  
บ้านให้นาง ต. เดือนละ 3,000 บาท นางสาว ต. ให้การว่าผู้เสียหายเล่าเรื่องให้ฟังว่า  
จำเลยพาผู้เสียหายไปที่ต่าง ๆ และกระทำอนาจารกับกระทำชำเราผู้เสียหาย เห็นได้

ว่า ผู้เสียหายเบิกความและให้การต่อพนักงานสอบสวนถึงพฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยเป็นขั้นตอนมีรายละเอียดไม่ขัดแย้งหรือมีพิรุธน่าสงสัย ผู้เสียหายยังชี้ภาพของสถานที่เกิดเหตุและรถยนต์ที่จำเลยใช้ขับมารับผู้เสียหาย นาง ต. ซึ่งรูปของจำเลยว่าเป็นผู้ขอให้ผู้เสียหายไปร่วมหลับนอน ผู้เสียหายอายุ 14 ปีเศษ ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยไม่น่าจะเบิกความปรักปรำให้ร้ายจำเลยเพื่อได้รับโทษทางอาญา นาง ต. เคยเป็นลูกจ้างของจำเลย ไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย นางสาว ด. เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ผ. ไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อนไม่มีเหตุผลที่จะเบิกความให้ร้ายจำเลย และเรื่องที่นาง ต. ให้การเป็นเรื่องที่สร้างความเสื่อมเสียแก่ผู้เสียหายบุตรสาวของตน หากไม่เป็นความจริงนาง ต. ไม่น่าจะกล้าให้การต่อพนักงานสอบสวนอันทำให้เสื่อมเสียแก่บุตรของตน ก่อนร้องทุกข์แพทย์ตรวจร่างกายของผู้เสียหายพบร่องรอยฉีกขาดของอวัยวะเพศที่ตำแหน่ง 5 ถึง 9 นาฬิกา ไม่พบอสุจิในและนอกอวัยวะเพศ พบสารคัดหลั่งของผู้ชายในอวัยวะภายนอกและภายในของผู้เสียหาย เมื่อนาง ต. ถูกพนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดฟ้องว่าเป็นผู้จัดให้จำเลยกระทำอนาจารและกระทำชำเราผู้เสียหาย นาง ต. ให้การรับสารภาพ แสดงว่านาง ต. เป็นผู้จัดให้จำเลยกระทำอนาจารและกระทำชำเราผู้เสียหายจริง พยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมาประกอบกันมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า จำเลยพาผู้เสียหาย อายุ 14 ปี ไปที่ต่าง ๆ โดยจำเลยให้เงินแก่นาง ต. เดือนละ 3,000 บาท และจำเลยกระทำอนาจารกับกระทำชำเราผู้เสียหาย ส่วนที่จำเลยนำสืบว่า จำเลยไม่เคยขับรถยนต์ไปรับผู้เสียหาย ไม่เคยกระทำชำเราผู้เสียหาย จำเลยอายุ 81 ปี ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เสื่อมสมรรถภาพทางเพศมิได้กระทำความผิดนั้น คงมีตัวจำเลยเบิกความไม่มีพยานอื่นสนับสนุนมีน้ำหนักน้อยไม่อาจรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ คำเบิกความของผู้เสียหายมีรายละเอียดและมีพยานอื่นประกอบมีน้ำหนักรับฟังได้ แม้โจทก์มิได้นำนาย น. บิดาของผู้เสียหายและคนขายโรตีสี่ที่ทราบเรื่องจากมารดาของผู้เสียหายมาเบิกความก็ไม่ทำให้พยานหลักฐานของโจทก์ขาดน้ำหนัก การที่คำเบิกความของ



นางสาว ด. เป็นพยานบอกเล่า และการตรวจร่างกายของผู้เสียหายไม่พบสารคัดหลั่งของจำเลย แต่พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดังได้วินิจฉัยมา พยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมาไม่มีความสงสัยดังที่จำเลยฎีกา เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำเบิกความของผู้เสียหายว่านาง ด. พาผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กไปส่งให้จำเลย และจำเลยรับตัวผู้เสียหายไว้ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อนำตัวผู้เสียหายไปกระทำชำเรา ซึ่งจำเลยได้กระทำแล้วหลายครั้ง ทั้งยังไปติดตามผู้เสียหายในที่สาธารณะโดยส่งเสียงไว้วาญจนบุคคลในสถานที่ดังกล่าวสามารถสังเกตได้ถึงความผิดปกติ การกระทำของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจเหนือผู้เสียหายที่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจที่ตนไม่อาจปฏิเสธได้เพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้เสียหายในทางเพศโดยการกระทำชำเราผู้เสียหายแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ที่นาง ด. ได้รับจากจำเลย อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น ทั้งการกระทำของจำเลยยังเป็นการทำให้ผู้เสียหายมีฐานะคล้ายทาส อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบ จึงเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์

อนึ่ง โจทก์บรรยายฟ้องสำหรับความผิดฐานค้ามนุษย์ว่า จำเลยกระทำความผิดเมื่อระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลากลางวัน ต่อเนื่องกัน โดยเป็นการบรรยายฟ้องในลักษณะต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่จำเลยกระทำพฤติการณ์ดังกล่าวจนถึงวันสุดท้ายที่จำเลยกระทำความผิดเมื่อพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 ใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ก่อนวันสุดท้ายที่จำเลยกระทำความผิดโดยให้ยกเลิกความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความตามมาตรา 6 ที่บัญญัติใหม่แทน ซึ่งการกระทำของจำเลยตามฟ้องยังคงเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ และคงกำหนดโทษตามมาตรา 52 อันเป็นระวางโทษเดิม กฎหมายเดิม

และที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึงเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำผิดด้วยกัน และเมื่อ  
กฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่เป็นคุณ จึงต้องบังคับตามกฎหมายเดิมและที่แก้ไขเพิ่ม  
เติมดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง สำหรับข้อที่โจทก์ฟ้อง  
ว่าจำเลยกระทำอนาจารและกระทำชำเราผู้เสียหาย โจทก์บรรยายฟ้องทำนองว่า เมื่อ  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562  
เวลากลางวัน ต่อเนื่องกัน จำเลยใช้อวัยวะเพศและนิ้วสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ  
ของผู้เสียหาย โดยศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยกระทำความผิดก่อนพระราชบัญญัติแก้ไข  
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ และพิพากษา  
ลงโทษจำเลยฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 279 วรรคหนึ่ง (เดิม) นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม  
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา  
277 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความใหม่แทน และมาตรา 3 ของพระ  
ราชบัญญัติดังกล่าว ให้เพิ่มนิยามของการกระทำชำเราเป็นมาตรา 1 (18) ของ  
ประมวลกฎหมายอาญาว่า "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่  
ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล้วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ  
ช่องปากของผู้อื่น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และโดยที่มาตรา  
277 วรรคสอง (เดิม) บัญญัติให้การกระทำชำเราหมายความรวมถึงการใช้สิ่งอื่นใด  
กระทำกับอวัยวะเพศของผู้อื่น ซึ่งการใช้นิ้วล้วงล้าเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้อื่นจึง  
ถือว่าเป็นการกระทำชำเราด้วย ดังนั้น ก่อนกฎหมายแก้ไข การใช้อวัยวะเพศและนิ้ว  
สอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายจึงเป็นความผิดฐานกระทำชำเราตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง (เดิม) เพียงบทเดียวเท่านั้น และเมื่อ  
กฎหมายแก้ไขแล้ว การใช้นิ้วล้วงล้าเข้าไปในอวัยวะเพศของผู้อื่นจึงไม่เป็นการ  
กระทำชำเราตามมาตรา 277 อีกต่อไป แต่จะเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารโดย  
การล้วงล้าอวัยวะเพศตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสี่ (ที่แก้ไขใหม่)

มิใช่ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตามมาตรา 279 วรรคหนึ่ง (เดิม) ตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย นอกเหนือไปจากการกระทำความผิดฐานกระทำชำเราตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่) ด้วย แต่เมื่อการใช้อวัยวะเพศและนิ้วสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของผู้เสียหายเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องเป็นคราวเดียวกันโดยความมุ่งหมายที่จะกระทำชำเราผู้เสียหาย การกระทำอนาจารของจำเลยจึงเป็นการกระทำที่รวมอยู่ในการกระทำชำเรา จึงเป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท และแต่ละบทมีอัตราโทษเท่ากัน คือมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท ซึ่งต้องให้ลงโทษฐานกระทำชำเรา และเมื่อการจะปรับบทลงโทษตามความผิดทั้งสองฐานตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 ต่างก็มีอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตามมาตรา 277 วรรคหนึ่งตามกฎหมายเดิมซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทต้องถือว่าไม่เป็นคุณแก่จำเลย จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลย ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นฎีกา ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขโดยปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 ที่ศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษาแก่ส่วนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม) ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อการกระทำความผิดฐานค้ำมนุษย์ของจำเลยเป็นกรรมเดียวกันกับความผิดฐานกระทำชำเราดังกล่าว จึงต้องลงโทษจำเลยตามความผิดฐานค้ำมนุษย์ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (2) วรรคหนึ่ง (เดิม), 6 (2) วรรคหนึ่ง, 52 วรรค

สาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคหนึ่ง (เดิม) การกระทำของจำเลย  
เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานค้ำมนุษย์ซึ่งได้  
กระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ส่วนโทษและนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประชา งามล้ำวง-สิริกานต์ มีจุล-วิชัย ช่างหัวหน้า)

ศาลจังหวัดแม่สอด - นายทรงศักดิ์ สุยะลา  
ศาลอุทธรณ์ - นายสมเจตน์ สุรินทร์ศักดิ์

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |